

1503513-34.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/03/2022
... de Justiça de São Paulo:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência" (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503513-34.2021.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272531/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20673946 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5650/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2272531 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EMERSON JOSE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

EMERSON JOSÉ DOS SANTOS está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 141), o réu apresentou defesa (fls. 152/157).

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 162/163) e o réu foi citado (fls. 214).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 221).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 221).

A defesa arguiu a nulidade da busca realizada e pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou, se o caso, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da mesma norma e, finalmente, teceu considerações acerca da aplicação da pena (fls. 221).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 19 e 41/48), informação (fls. 93/94), laudos periciais (fls. 100/103 e 173/178), além da prova oral colhida na fase instrutória.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou a acusação. Disse que havia ido até o local dos fatos para adquirir drogas de "Alemão", que jogou as chaves do portão pela sacada para que entrasse. Como estava sem dinheiro e "Alemão" negou-se a lhe vender drogas "fiado", deixou seu celular no local como garantia de que voltaria para pagar as três porções que adquiriu, uma das quais usou no local. Ao sair, deixou as chaves no portão e seguiu rumo a sua casa, quando foi abordado. Durante a revista, os policiais encontraram as duas porções de cocaína e o levaram até o imóvel em tela. Lá chegando, ouviu os policiais gritando "correu". Já dentro da viatura, um policial lhe pediu para que desbloqueasse o celular, o que atendeu e repetiu na delegacia. Negou ser o proprietário do imóvel ou que comercialize drogas.

O policial civil Aguinaldo relatou ter recebido informações de que o réu era um dos maiores traficantes do Bairro Maria Luiza IV e que havia adquirido um imóvel na rua Pascoal Salmazo para o armazenamento de drogas. Na data dos fatos, avistou o acusado em frente ao imóvel e ele, ao visualizar a viatura, bateu o portão e saiu andando, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, localizou com o réu um molho de chaves, além de duas porções de cocaína. Indagado acerca da destinação da droga, ele afirmou que só se manifestaria em juízo ou na presença de seu advogado. Após constatar que a chave era do imóvel, procedeu à busca no local, onde encontrou, dentro de um armário ao lado da churrasqueira, uma carteira com os documentos pessoais do acusado, além de R\$200,00. O celular dele estava conectado à tomada. No local também havia mais 20 porções de cocaína idênticas às encontradas com o réu e embalagens costumeiramente usadas na mercancia ilícita. Não havia móveis no local nem outras pessoas. A porta dos fundos da casa estava trancada por dentro e não haveria como alguém sair dali. Solicitou a vinda dos cachorros da polícia, mas nada mais foi encontrado. Não realizou busca na casa onde o acusado reside e tampouco ouviu vizinhos.

O policial militar Caíque confirmou, em linhas gerais, o depoimento de seu colega de farda e acrescentou nunca ter abordado o réu anteriormente.

A testemunha Ismael narrou que conhece Emerson há 10 anos, moram no mesmo bairro e sabe que ele trabalha na construção civil. Disse que estava em um bar no momento da prisão e viu quando o réu foi abordado e uma pessoa saiu correndo. Não sabe quem é o proprietário do imóvel onde os fatos ocorreram, todavia o acusado não costuma frequentar o local, que é ponto de venda de drogas.

A testemunha Laura mencionou morar nas proximidades do imóvel onde o réu foi preso e sabe que a casa não é dele, pois o local é uma biqueira, que continua funcionando

após a prisão. Viu o réu sendo abordado e sabe que ele trabalha com reciclagem e obras.

As provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao réu.

De saída, não merece guarida a alegação defensiva de nulidade da busca. Os policiais afirmaram que, para além das denúncias de que o réu praticava o comércio espúrio no local, ele foi abordado na posse de duas porções de cocaína, circunstâncias que revelavam fundada suspeita da prática de crime permanente no imóvel e autorizavam o ingresso.

Nesse sentido: "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental da privacidade. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. Na espécie, que a entrada dos policiais no domicílio do paciente, ora agravante, se deu de forma lícita, tendo em vista os fatos narrados no inquérito policial e na instrução criminal, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no HC: 536355 SP 2019/0292244-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Noutra ponta, a versão apresentada pelo acusado em juízo não se sustenta, já que em sua carteira havia cerca de R\$200,00 (fls. 12/13), o que afasta a justificativa para ter deixado o celular e documentos no local.

Os policiais militares apresentaram relatos coerentes e harmônicos e afirmaram que não viram mais ninguém no local e que a porta dos fundos do imóvel estava trancada por dentro, o que não permitia fuga por ela. Eles também disseram que o celular do acusado estava conectado a um carregador, o que também vai de encontro a sua narrativa.

E não se vislumbra motivo capaz de colocar em xeque tais depoimentos, até porque, a despeito das declarações genéricas do acusado de que estaria sendo perseguido, ele mencionou que sequer conhecia os milicianos envolvidos na ocorrência.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

A despeito das alegações das testemunhas de defesa de que a biqueira continua funcionando após a prisão do acusado, não há como afastar a possibilidade de que ele agisse em conluio com outros traficantes, que podem ter dado continuidade ao comércio espúrio no local.

No mais, o fato de o réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que, como cediço, elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência" (...)" (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)" (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não verifico motivos aptos a ensejar a oscilação da pena-base, que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, aponto a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo - ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral

do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Presente, ainda, a agravante da reincidência, que é específica (Proc. 0005750-28.2015 – fls. 116/118). Assim, aumento a pena de 1/4 para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência do réu enseja o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão"

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das

Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu EMERSON JOSÉ DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente em virtude da necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos e do dinheiro apreendidos.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA